



**Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales-ITRC**

DEBIDO PROCESO/CONSTITUCIÓN POLÍTICA ARTÍCULO 29

Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

DEBIDO PROCESO /SENTENCIA CORTE CONSTITUCIONAL

Principio inherente al Estado de Derecho, cuyas características esenciales son el ejercicio de funciones bajo parámetros normativos previamente establecidos y la erradicación de la arbitrariedad

DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO/ SENTENCIA CORTE CONSTITUCIONAL

La jurisprudencia constitucional ha diferenciado entre las garantías previas y posteriores que implica el derecho al debido proceso en materia administrativa. Las garantías mínimas previas se relacionan con aquellas garantías mínimas que necesariamente deben cobijar la expedición y ejecución de cualquier acto o procedimiento administrativo, tales como el acceso libre y en condiciones de igualdad a la justicia, el juez natural, el derecho de defensa, la razonabilidad de los plazos y la imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces, entre otras. De otro lado, las garantías mínimas posteriores se refieren a la posibilidad de cuestionar la validez jurídica de una decisión administrativa, mediante los recursos de la vía gubernativa y la jurisdicción contenciosa administrativa.

**EXTENSION DE GARANTIAS DEL DEBIDO PROCESO AL AMBITO ADMINISTRATIVO/
SENTENCIA CORTE CONSTITUCIONAL**

La extensión de las garantías del debido proceso al ámbito administrativo no implica, sin embargo, que su alcance sea idéntico en la administración de justicia y en el ejercicio de la función pública. A pesar de la importancia que tiene para el orden constitucional la vigencia del debido proceso en todos los escenarios en los que el ciudadano puede ver afectados sus derechos por actuaciones públicas (sin importar de qué rama provienen), es necesario que la interpretación de las garantías que lo componen tome en consideración los principios que caracterizan cada escenario, así como las diferencias que existen entre ellos.¹

¹ Sentencia C-034/14

POR EL CUAL SE RESUELVE EN SEGUNDA INSTANCIA EL RECURSO DE APELACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE 1704-01-2015-194

Dependencia:	Dirección General
Número del Proceso:	1704-01-2015-194
Número y fecha del fallo:	Fallo No. 0006 del 19 de abril de 2016
Asunto:	Fallo de segunda instancia
Criterio de Selección:	Fallo revocar totalmente la Resolución No. 17317-00036 del 23 de diciembre de 2016

FALLO NO. 0006 DEL 19 DE ABRIL DE 2017

POR EL CUAL SE RESUELVE EN SEGUNDA INSTANCIA EL RECURSO DE APELACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE 1704-01-2015-194

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto por el Abogado XXXXX XXXXX, apoderado de confianza de los disciplinados XXXXX XXXXX y XXXXX XXXXX, contra la Resolución No. 17317-00036 de fecha 23 de diciembre de 2016, por medio de la cual la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de esta Agencia profirió fallo sancionatorio de primera instancia dentro del proceso administrativo disciplinario No. 1704-01-2015-194.

COMPETENCIA

La suscrita Directora General (E) de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC, es competente para resolver la presente impugnación en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 4173 de 2011, aclarado por el Decreto 4452 de 2011, en atención a las previsiones contenidas en los numerales 12 y 13 del artículo 3o del Decreto 0985 del 14 de mayo de 2012, y al contenido del artículo 171 de la Ley 734 de 2002.

HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES

La actuación se originó en el oficio de fecha 8 de abril de 2013, a través del cual la entonces Directora Seccional de Aduanas de Bogotá informó algunas posibles irregularidades ocurridas en el trámite aduanero que culminó con la expedición del acta de aprehensión No. 03-01429 de 18 de julio de 2012, de una parte, porque la misma fue enviada para notificación 12 días calendario después de expedirse el DIAM y de otra, porque la mercancía restante fue objeto de levante sin que se formulara controversia de valor por "precios ostensiblemente bajos", respecto de los precios de referencia que tenía ese tipo de mercancía (folios 3 a 5).

Por los hechos descritos, la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, mediante auto No. 1001-167 de 23 de abril de 2013, dispuso la apertura de una indagación preliminar disciplinaria en contra de los funcionarios XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX y XXXXX XXXXX (folio 22).

Más adelante, a través de decisión No. 7702-00242 de 6 de noviembre de 2013, evaluó las pruebas recaudadas en etapa preliminar y ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra de los mismos implicados (folios 100 y 101).

Posteriormente, con auto fechado 2 de julio de 2015 (folio 457), dicha Subdirección ordenó el cierre de la etapa de investigación disciplinaria con fundamento en el artículo 160 A de la Ley 734 de 2002 y a continuación, con proveído de 27 de agosto de 2015, ordenó la remisión de la actuación disciplinaria a esta unidad administrativa especial en atención a la competencia establecida en el Decreto Legislativo 4173 de 2011 (folio 468).

POR EL CUAL SE RESUELVE EN SEGUNDA INSTANCIA EL RECURSO DE APELACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE 1704-01-2015-194

Como consecuencia de la actuación anterior, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de esta Agencia, mediante auto No. 1740600011 de fecha 14 de julio de 2016, llamó a responder disciplinariamente a los encartados XXXXX XXXXX y XXXXX XXXXX, por haber incurrido- al parecer- en la falta disciplinaria gravísima prevista en el artículo 48 numeral 50 de la Ley 734 de 2002, al tiempo que ordenó el archivo de las diligencias frente al encartado XXXXX XXXXX (folios 829 a 841).

Luego, con decisiones de 7 de septiembre de 2016 y 6 de octubre de 2016, el a quo resolvió las pruebas solicitadas en etapa de descargos (folios 977 a 978 vto. y 1065 a 1067).

Y finalmente, tras agotar la etapa probatoria de juicio dispuesta a partir de las decisiones anteriores y de correr traslado para alegar de conclusión (folio 1293), el operador profirió fallo de primera instancia mediante Resolución No. 17317-00036 de 23 de diciembre de 2016 (folios 1317 a 1336), a través de la cual declaró disciplinariamente responsable a los servidores XXXXX XXXXX y XXXXX XXXXX por la falta gravísima que fue objeto de acusación y en consecuencia, les impuso sanción de destitución del cargo e inhabilidad general por el término de diez (10) años.

La anterior decisión, una vez notificada personalmente (folio 1341), fue impugnada de manera oportuna por la defensa (folios 1345 a 1367), concediéndose la alzada con auto de fecha 20 de enero de 2017 (folio 1368) y siendo recibidas en este Despacho el día 24 de enero de 2017.

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN APELADA

El fallo de primera instancia principió con un recuento de la identidad de los procesados, los hechos que fueron objeto de investigación y los cargos por los cuales fueron llamados a responder disciplinariamente los enjuiciados. A continuación, se resumieron los argumentos expuestos por la defensa y las explicaciones que el investigado XXXXX XXXXX dio en versión libre.

Inmediatamente después, en el capítulo "CONSIDERACIONES DE INSTANCIA", el a quo motivó las razones de su decisión, para lo cual refirió la normatividad que le dio competencia legal para fallar el asunto y a renglón seguido, resumió y valoró las pruebas documentales y testimoniales que fueron recaudadas durante toda la actuación disciplinaria.

Así, documentalmente tuvo en cuenta la noticia disciplinaria y sus anexos, las respuestas iniciales que sobre el asunto entregaron la entonces Jefe de la División de Gestión de Fiscalización Aduanera de Bogotá y el funcionario XXXXX XXXXX, el listado de precios de referencia de medias y calcetines para la vigencia 2009- 2011, la explicación sobre el sistema de administración de riesgos SAR contentivo de los precios de referencia y si era obligatoria su utilización, el extracto de historia laboral de los disciplinados, el proceso de definición de situación jurídica de la mercancía DM-2012-2012-2889 y copia del reglamento Comunitario 571 sobre el valor en aduana de mercancía importada.

Por su parte, testimonialmente valoró las declaraciones de los señores XXXXX XXXXX, antigua Jefe de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, XXXXX XXXXX, entonces Directora Seccional de Aduanas de Bogotá, XXXXX XXXXX, Subdirectora de Gestión de Comercio Exterior de la DIAN, XXXXX XXXXX, funcionario de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá y XXXXX XXXXX, funcionario de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali.

POR EL CUAL SE RESUELVE EN SEGUNDA INSTANCIA EL RECURSO DE APELACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE 1704-01-2015-194

Con el anterior material probatorio, el operador de primera instancia consideró abastecidos los elementos constitutivos de la falta disciplinaria que fue objeto de acusación, reiterando los criterios de tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad que formuló en el auto de pliego de cargos.

En ese orden de ideas, en cuanto a la tipicidad, el director del proceso concluyó que los disciplinados incurrieron en la descripción contenida en el artículo 48 numeral 50 de la Ley 734 de 2002, porque omitieron realizar la controversia de valor frente a los precios ostensiblemente bajos en la mercancía presentada por el importador, lo que pudieron haber comprobado con los precios de referencia de la DIAN y ante lo cual debieron exigir una garantía o el pago de los valores correctos, como lo establece el numeral 5.1.3 del artículo 128 del decreto 2685 de 1999, el numeral 30 del artículo 54 del Reglamento Comunitario adoptado por la Resolución 846 de la CAN, los numerales 4 y 5 de la Resolución Reglamentaria 4240 de 2000 de la DIAN y el artículo 2° del Reglamento Comunitario de la Decisión 571. Lo anterior en provecho del importador porque no se incrementaron los valores para el pago de tributos, rescates y derechos antidumping, ni se dio inicio al proceso sancionatorio en su contra por haber declarado un valor inferior al precio oficialmente establecido.

En relación con la ilicitud sustancial, el fallador de primera instancia concluyó que el incumplimiento del deber funcional fue sustancial y no formal, porque la omisión de realizar la controversia de precios cuando existían precios ostensiblemente bajos, ocasionó que el recaudo de la DIAN sobre dicha mercancía fuera exageradamente bajo al que en realidad correspondía, con desconocimiento de los principios de moralidad pública, responsabilidad y transparencia. Además, que ello se demuestra cuando los deberes del servicio público se vieron contrariados por la conducta exteriorizada de los implicados, en detrimento de la DIAN, sin dar cumplimiento a la norma aduanera, favoreciendo a un tercero y sin que existiera causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.

Y respecto de la culpabilidad, el a quo dio por establecidos los elementos cognoscitivo y volitivo del dolo, porque los comportamientos de los enjuiciados son de aquellos que necesariamente requieren del conocimiento, del querer y de la conciencia del actor, y también, porque ellos han laborado un tiempo considerable en la DIAN y por ende comprenden los deberes funcionales, las responsabilidades que dicha condición les impone y la normatividad aduanera que debieron aplicar, a pesar de lo cual otorgaron el levante de la mercancía con unos valores inferiores a los precios de referencia y que por su naturaleza era considerada sensible.

En el capítulo siguiente, la primera instancia no les dio crédito a los alegatos expuestos por la defensa, en los siguientes términos: en primer lugar, en cuanto al argumento de que no se debía realizar la controversia de valor porque el avalúo de mercancía se realiza conforme a la Resolución 2201 de 2005, el a quo consideró que no le asiste razón al apelante porque, (i) la misma resolución establece que el funcionario aprehensor debe verificar si mercancías idénticas o similares a la aprehendida se encuentran registradas en la base de precios, disposición que es de obligatorio cumplimiento porque fue emitida por el Director General de la DIAN conforme a las funciones establecidas en el Decreto 4048 de 2008; (ii) el artículo 172 de la Resolución 4240 de 2000- reglamentaría del Decreto 2685 de 1999- establece que ante precios ostensiblemente bajos es posible el levante de la mercancía si se ajusta el precio en la declaración de importación o se constituye una garantía; (iii) dentro de las funciones de los inspectores aduaneros se encuentra verificar los requisitos establecidos para la importación y realizar la inspección para determinar la procedencia del levante; (iv) los funcionarios pueden imponer medidas cautelares si se encuentran mercancías declaradas por debajo de los precios indicativos o del margen inferior de los precios estimados, conforme al literal K del artículo 470 del estatuto aduanero y eso da lugar a la imposición de la sanción referida en el artículo 499 del estatuto aduanero; y (v) el grupo al que pertenecían los investigados para la fecha de los hechos tenía funciones relacionadas con realizar inspección aduanera a las mercancías

POR EL CUAL SE RESUELVE EN SEGUNDA INSTANCIA EL RECURSO DE APELACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE 1704-01-2015-194

para determinar su conformidad con lo declarado, generar y fundamentar las controversias, e inmovilizar, aprehender o efectuar el decomiso directo.

En segundo lugar, en cuanto al argumento de que el listado de precios de calcetería no se encontraba vigente para la fecha de los hechos porque regía hasta el año 2012, el operador de primera instancia desestimó dicha apreciación porque el acta de aprehensión, la declaración de importación y el acta de hechos, datan del mismo año 2012.

En tercer lugar, respecto del argumento de que la base de datos no conduce al rechazo automático del valor de transacción declarado y de que no se han emitido lineamientos o directrices que indiquen la obligatoriedad de consulta de los listados de precios como procedimiento para inspeccionar mercancías a nacionalizar, pues estos tienen carácter indicativo, el director del proceso no realizó algún pronunciamiento y en cambio, en cuarto lugar, frente al argumento de que la DIAN cuenta con varias bases de datos, una de las cuales sirve para realizar el DIAM, el fallador de instancia admitió la existencia de otras bases de precio pero consideró que todas ellas demuestran que los precios declarados fueron ostensiblemente bajos.

Finalmente, en quinto lugar, en relación con el argumento de que no es suficiente el hecho de que el valor declarado sea inferior a los precios corrientes o de mercado, para descartar la aplicación del método de valor de la transacción, porque la entidad cuenta con otras herramientas posteriores a haber otorgado el levante, para comprobar que el precio declarado corresponde efectivamente al precio pagado, el subdirector de investigaciones disciplinarias reiteró el contenido del artículo 172 de la Resolución 4240 de 2000, que permite el levante de la mercancía con precios ostensiblemente bajos, si el declarante ajusta voluntariamente el precio en la declaración de importación o constituye una garantía en las formas dispuestas en los artículos 523 y 527 de la misma resolución.

A continuación, en lo relativo a la calificación de la falta, el a quo mantuvo la imputación de falta disciplinaria gravísima, dado que se ajustó a la descripción del artículo 48 numeral 50 de la Ley 734 de 2002.

V por último, el operador de primera instancia realizó la dosificación de la sanción a imponer con fundamento en los artículos 44, 46 y 47 de la Ley 734 de 2002, para lo cual partió, primero, de los límites legales de diez (10) a veinte (20) años establecidos para la inhabilidad general complementaria de la sanción de destitución, a su vez establecida para las faltas gravísimas dolosas y segundo, de los siguientes criterios tenidos en cuenta a favor de los disciplinados: la ausencia de antecedentes disciplinarios, la diligencia y eficiencia en el desempeño del cargo, el hecho de no haber atribuido responsabilidad a un tercero, haber procurado resarcir el perjuicio, no haber afectado derechos fundamentales y no pertenecer al nivel directivo o ejecutivo de la entidad. Por lo tanto, impuso sanción de destitución del cargo e inhabilidad general por el término de diez (10) años.

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO

El apoderado señaló en su alzada que la entonces Directora Seccional de Aduanas de Bogotá incumplió su deber porque no remitió la documentación a la División de Gestión de Fiscalización para que efectuara el estudio de valor, siendo ésta la competente para determinar en control posterior el valor en aduana de las mercancías importadas y a renglón seguido manifestó que del testimonio de la Subdirectora de Gestión de Comercio Exterior de la DIAN, se concluye que los precios de referencia son un parámetro no obligatorio porque la OMC prohíbe la fijación de tales precios, que es imposible detectar fraude o subfacturación en la diligencia de inspección porque para ello se requiere de pruebas y tiempo, y que el método de valoración por excelencia de la OMC es el valor de transacción de mercancías importadas visible en la factura.

POR EL CUAL SE RESUELVE EN SEGUNDA INSTANCIA EL RECURSO DE APELACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE 1704-01-2015-194

Expresó que su representada XXXXX XXXXX no generó la controversia de valor porque no contaba con los datos objetivos y cuantificables para generarla, y por lo tanto, aceptó el valor de la transacción consignado en la factura comercial, más aún cuando la Coordinación del Servicio de Valoración de la DIAN indicó en esta investigación, que los precios de referencia son una herramienta que los funcionarios pueden utilizar junto con otras fuentes de información, que pueden ser consultados cuando se suscite una duda razonable de conformidad con el artículo 171 de la Resolución 4240 de 2000 y que dicha dependencia "nunca ha emitido lineamiento o directrices indicando la obligatoriedad de consulta de los listados o las bases de precios de referencia como procedimiento para inspeccionar mercancías a nacionalizar".

Por lo anterior, cuestionó que su protegida haya sido sancionada porque no consultó la base de precios SAR, cuando la Coordinación del Servicio de Valoración de la DIAN precisó que no es obligatoria dicha consulta al momento de inspeccionar las mercancías y cuando a ella no se le generó duda en cuanto al precio soportado en la factura. Todo teniendo presente que la División de Gestión de Fiscalización podía generar la controversia de valor en actuaciones de control posterior y si no la generó dentro del proceso de definición de situación jurídica, es porque no existieron argumentos para ello.

Señaló en cuanto al tipo disciplinario, que tampoco se acreditó que la actuación de la disciplinada hubiera sido en provecho de un tercero, porque no se precisó en qué consistió el beneficio ni qué tercero se benefició y en relación con la violación del régimen aduanero, reiteró que la normatividad aduanera no establecía la obligatoriedad de consultar la base de precios.

En párrafo siguiente mencionó la prueba obrante en el folio 700 del expediente de definición de situación jurídica, la cual da cuenta del registro en la contabilidad de la sociedad de la factura tenida en cuenta por ía encartada y que, debido a ella, quedó sustentado el valor de la transacción, por lo que no era necesario generar la controversia de valor.

Por otra parte, alegó que la actuación del procesado XXXXX XXXXX se circunscribió a dar levante a unas declaraciones de legalización conforme a lo ordenado por la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, según da cuenta el folio 651 del expediente de definición de situación jurídica, dependencia que autorizó la presentación de la declaración de legalización con el pago del rescate del 75%, la cual se debe presentar sobre el valor FOB declarado inicialmente, es decir, el consignado en la factura, sin que fuera viable generar controversia de valor porque el valor de transacción fue aceptado.

También desvirtuó el provecho exigido en el tipo disciplinario porque el valor declarado es diferente del valor dado por la autoridad aduanera en el DIAM y por lo tanto, no podía generarse controversia de valor por éste último valor al momento de la inspección aduanera, en razón a que las bases para expedirlo son diferentes- como lo expusieron los testigos, es decir, una es la base de precios para realizar el DIAM, otra la base de precios SAR y otra la consulta de precios ostensiblemente bajos, por lo que no es acertado concluir que la diferencia entre el precio consignado en la factura y el DIAM, fue entre el 93% y 97%.

Insistió que para el momento en que se realizó la inspección y levante de la mercancía (10 de enero de 2013), los precios de la base del sistema de administración de riesgos de calcetería no se encontraban vigentes, ya que regían hasta el año 2012 y a continuación reiteró el contenido de la respuesta dada por la Coordinación del Servicio de Valoración de la DIAN resumida líneas atrás, para concluir que la actuación de su representado no se enmarcó dentro de la falta gravísima por la que fue sancionado, tampoco existió ilicitud sustancial en su comportamiento y mucho menos tuvo un proceder doloso porque solo

POR EL CUAL SE RESUELVE EN SEGUNDA INSTANCIA EL RECURSO DE APELACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE 1704-01-2015-194

impartió levante a la declaración de legalización previa autorización de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá.

Finalmente, arguyó una errónea valoración probatoria porque el a quo no hizo un análisis o una valoración de las razones y fundamentos que le daban elementos de convicción, tampoco explicó por qué no aceptó las decisiones judiciales en las cuales se acogió el criterio de que no generar controversia de valor en el proceso de inspección no constituía falta disciplinaria y menos se sabe de dónde extrajo que la conducta de sus representados fue dolosa.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Ante todo, se recuerda que conforme lo previsto en el párrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, "el recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación".

También, que el artículo 116 ibídem prohíbe al Superior, "en la providencia que resuelva el recurso de apelación interpuesto contra el fallo sancionatorio", agravar la sanción impuesta cuando el investigado sea apelante único.

Y del mismo modo, que el artículo 144 ídem permite la declaratoria oficiosa de la nulidad "en cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario que conozca del asunto advierta la existencia de alguna de las causales".

De esta manera, la competencia de esta Dirección se encuentra limitada, en un comienzo, a los aspectos que fueron controvertidos en la apelación o que guardan relación inescindible con aquellos, en cuya labor tiene prohibido agravar la sanción impuesta al investigado cuando sea apelante único y en todo caso, podrá declarar oficiosamente la nulidad de lo actuado si advierte la existencia de alguna de las causas que la generan.

Así las cosas, el Despacho estudiará el recurso interpuesto bajo los parámetros indicados y emitirá un pronunciamiento de fondo que resuelva los cuestionamientos de la defensa.

En ese orden de ideas, la inconformidad de la defensa radica en los siguientes tres aspectos: (i) que la consulta de los precios de referencia no era obligatoria y por lo tanto la procesada XXXXX XXXXX no debía generar controversia de porque no tuvo duda en cuanto al precio soportado en la factura; (ii) que la actuación del procesado XXXXX XXXXX se circunscribió a dar levante a unas declaraciones de legalización conforme lo había ordenado la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, en la cual no era viable generar controversia de valor porque el valor de la transacción ya había sido aceptado; y (iii) que en ningún caso se demostró el provecho de un tercero ni la modalidad dolosa que exige el tipo disciplinario.

No obstante, el operador de primera instancia sancionó a los investigados XXXXX XXXXX y XXXXX XXXXX, únicamente porque violaron las disposiciones del régimen aduanero contenidas en los numerales 5.1.3 del artículo 128 del Decreto 2685 de 1999 y 4 y 5 del artículo 172 de la resolución 4240 de 2000, en cuanto no generaron la controversia de valor por precios ostensiblemente bajos respecto de las declaraciones de importación inicial, de corrección y de legalización que inspeccionaron .

Y para arribar a la anterior conclusión, el a quo presumió que los disciplinados XXXXX XXXXX y XXXXX XXXXX debieron consultar y tener en cuenta los precios de referencia de la DIAN al momento de la inspección aduanera, porque así habrían verificado la presencia de los precios ostensiblemente bajos en las declaraciones inspeccionadas, pero como no lo hicieron, no generaron la controversia de valor que les fue reclamada en la decisión de primera instancia.

POR EL CUAL SE RESUELVE EN SEGUNDA INSTANCIA EL RECURSO DE APELACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE 1704-01-2015-194

Por lo tanto, este Despacho considera que el problema jurídico está en determinar, primero, si los procesados tenían el deber funcional de realizar consulta a los precios de referencia de la DIAN al momento de inspeccionar las declaraciones de importación, de corrección y de legalización, para que hubieran detectado los precios ostensiblemente bajos y en consecuencia hubieran generado la controversia de valor exigida por la normatividad aduanera, y segundo, en el evento de que si hubieran tenido el deber funcional, si dicha omisión fue dolosa y con la misma se generó provecho a un tercero, como lo exige el tipo disciplinario.

Así pues, en cuanto al primer cuestionamiento, distintas referencias normativas y probatorias obrantes en la actuación enseñan que los enjuiciados no tenían el deber funcional de consultar los precios de referencia sobre medias y calcetines cuando realizaron la inspección aduanera.

En efecto, el Reglamento Comunitario de la Decisión 571- Valor en Aduanas de las Mercancías importadas, aprobado por la Comunidad Andina mediante Resolución 846, en su artículo 49 establece que los precios ostensiblemente bajos son un factor de riesgo e indica que si con base en tales factores de riesgo se detecta "una duda razonable", se debe iniciar la investigación pertinente de valor. Además, en el numeral 3o del artículo 53 indica que "los precios de referencia deben ser tomados con carácter Indicativo para el control del valor declarado para las mercancías Importadas" y que "podrán servir para sustentar las dudas sobre el valor declarado que surjan entre la autoridad aduanera y el declarante" (subraya el Despacho) (folios 206 a 226).

El artículo 237 del Decreto 2685 de 1999 define los precios de referencia en los mismos términos que el literal g) del artículo 2o del Reglamento Comunitario y adiciona que "El uso de los precios de referencia no conlleva al rechazo automático del Valor de Transacción declarado para las mercancías importadas". Es decir, los precios de referencia y el valor declarado no son excluyentes.

El artículo 171 de la Resolución 4240 de 2000 (reglamentaria del Decreto 2685 de 1999) indica que los precios de referencia "deben tomarse como una medida de control durante la diligencia de inspección" y que, conforme el artículo 53 del reglamento comunitario, "sustentan las dudas del valor declarado por las mercancías importadas". Además, en el artículo 172, numeral 3o, literal a), indica que en caso de controversia por duda sobre el valor declarado cuando es inferior a los precios de referencia, que se autorizará el levante si el declarante dentro de los dos (2) días siguiente a la práctica de la diligencia de inspección presenta los documentos soporte que acrediten el precio declarado".

En clara armonía con las disposiciones anteriores, los memorandos 0563 y 000082 de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera de la DIAN, establecen que en el control previo aduanero- como el realizado por los procesados, además de los precios de referencia "también pueden ser utilizados los que se encuentran en las fuentes citadas en el artículo 237" del Decreto 2685 de 1999 y que los funcionarios tienen la "obligación" de consultarlos "en forma periódica" porque de la misma manera se actualizan (folios 172 y vto.). Es decir, con estos dos actos administrativos se definió que los precios de referencia son una fuente de información y que es obligatorio consultarlos de forma periódica porque asimismo son actualizados.

En la misma línea, la Coordinación del Servicio de Valoración Aduanera de la DIAN señaló que la base de precios de referencia "puede ser utilizada" para fundamentar las dudas en la verificación del valor en aduana; que su uso no implica el "rechazo automático del valor de transacción declarado y que es una herramienta de control que los funcionarios "pueden utilizar junto con otras fuentes de información", para determinar la veracidad o exactitud del valor en aduana declarado (folios 65 y 171). Es decir, esta respuesta reitera que el uso de los precios de referencia se debe realizar si se presenta una duda razonable

POR EL CUAL SE RESUELVE EN SEGUNDA INSTANCIA EL RECURSO DE APELACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE 1704-01-2015-194

porque es una fuente de información de precios y su uso no desconoce el valor declarado por el importador.

En continuación con la misma idea, la Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos de la DIAN señaló que no se han "emitido lineamientos o directrices indicando la obligatoriedad de consulta de los listados o la base de precios de referencia como parte del procedimiento de inspección de mercancías a nacionalizar" (folio 165 vto.), lo cual ratifica que se trata de una fuente de información cuya consulta no es obligatoria.

Sumado a lo dicho, la Doctora XXXXX XXXXX, Subdirectora de Gestión de Comercio Exterior de la DIAN, declaró que durante el proceso de inspección se verifica que lo declarado corresponda con la documentación que se presenta, mientras que en el control posterior se determina "el valor en aduana de las mercancías importadas", es decir, que se haya aplicado uno de los métodos de valoración. Además, que en valoración aduanera es "obligatorio partir del precio realmente pagado o por pagar contenido generalmente en la factura comercial siempre y cuando corresponda al real de la negociación y no se tengan elementos para dudar de dicho precio". De igual manera, que los precios de referencia "solo se constituyen en un parámetro de comparación y su aplicación no es obligatorio" porque se convertirían en precios oficiales, lo cual se encuentra prohibido por la OMC. Así mismo, que para determinar si el valor declarado es ostensiblemente bajo se deben tener en cuenta todos los aspectos que puedan afectar el precio. Y, por último, que en la inspección física se debe verificar que la mercancía corresponda con la mercancía declarada, lo cual incluye una verificación del valor en aduana declarado pero que en esa oportunidad "no se determina valor en aduana" (folios 1008 a 1012).

Así las cosas, conforme lo anterior, este Despacho concluye que los enjuiciados XXXXX XXXXX y XXXXX XXXXX, no son disciplinariamente responsables por no haber formulado controversia de valor por precios ostensiblemente bajos respecto de las declaraciones de importación inicial, de corrección y de legalización que inspeccionaron, porque si ellos no tenían el deber funcional de consultar los precios de referencia de la DIAN sobre medias y calcetines cuando realizaron las inspecciones aduaneras.

Dicho en otros términos, los procesados, con su actuar, no infringieron deber funcional alguno porque no tenían la obligación de aplicar las disposiciones normativas del régimen aduanero que fueron reclamadas por el director del proceso, esto es, los numerales 5.1.3 del artículo 128 del Decreto 2685 de 1999 y 4 y 5 del artículo 172 de la resolución 4240 de 2000, si no tenían la duda razonable.

Al respecto, vale la pena recordar el contenido del artículo 60 de la Constitución Política que establece la cláusula general de responsabilidad al establecer que los particulares y los servidores públicos son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, y estos últimos, además, por omisión o extra limitación en el ejercicio de sus funciones.

Así mismo, el contenido de los artículos 50 y 22 de la Ley 734 de 2002, los cuales establecen, respectivamente, que la falta disciplinaria será antijurídica "cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna" y que el sujeto disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desarrollo de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

Por su parte, sobre el incumplimiento del deber funcional, el Honorable Consejo de Estado, en decisión de fecha 13 de febrero de 2014, radicado 11001-03-25-000-2011-00716-00(2718-11), consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expresó:

POR EL CUAL SE RESUELVE EN SEGUNDA INSTANCIA EL RECURSO DE APELACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE 1704-01-2015-194

Respecto de los componentes del derecho disciplinario, éste se encuentra integrado por todas aquellas normas sustantivas y adjetivas que exigen de los servidores públicos y de ciertos particulares, un específico comportamiento en el ejercicio de las funciones públicas, como la disciplina, la obediencia, la diligencia, el cuidado, la corrección y el comportamiento ético en el desempeño de las funciones asignadas y encomendadas a los servidores públicos, con el fin de asegurar la debida prestación y buena marcha de la función administrativa, en desarrollo de los principios constitucionales contenidos en el artículo 209 Superior. Por tanto, las infracciones al cumplimiento de dichos deberes, obligaciones, mandatos y prohibiciones constitucionales y legales para el adecuado e idóneo desempeño de la función pública, deben ser sancionadas disciplinariamente.

El resultado material de la conducta no es esencial para estructurar la falta disciplinaria, pues el solo deber origina la antijuridicidad de la conducta, sin embargo, no es el incumplimiento de dicho deber el que origina la falta, sino la infracción sustancial de dicho deber, es decir, aquella conducta que atente contra el buen funcionamiento de Estado.

Tiene su fundamento este análisis, en que las normas disciplinarias poseen como finalidad encauzar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes para cumplir los fines estatales, por ende, el objeto de protección del derecho disciplinario es el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública. Este soporte de responsabilidad se articula con las relaciones especiales de sujeción surgidas entre el Estado y el servidor público o el particular que cumpla funciones públicas, las cuales están orientadas a la consecución o materialización de los fines estatales.

Precisamente, este punto en donde se quebrantan deberes funcionales marca la diferencia sustancial con el concepto de dolo o culpa en el derecho penal. Mientras en el derecho disciplinario se infringen deberes funcionales, en el delito se vulneran bienes jurídicos, lo cual sin duda está relacionado con el principio de responsabilidad jurídica⁴ que delimita la obligación del servidor público, dado que este es responsable por infringir la constitución y la ley, por la omisión y extralimitación de sus funciones, y por el respeto a las prohibiciones y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. En materia penal la descripción de los hechos punibles es detallada, en tanto, en la disciplinaria el fallador cuenta con un mayor margen de valoración e individualización de las faltas sancionables por la diversidad de comportamientos que pugnan con los propósitos de la función pública y del régimen disciplinario. (Subraya del Despacho)

Y más adelante, en pronunciamiento calendado 6 de octubre de 2016, radicado 11001-03-25-000-2012-00681-00(2362-12), consejera ponente Sandra Lísset Ibarra Vélez, la aita corporación enseñó:

(...) se observa que los elementos que componen la responsabilidad disciplinaria, esto es aquellos que debe acreditar la autoridad disciplinaria a efectos imponer una sanción son: 1) la tipicidad que se traduce en que los destinatarios de la ley disciplinaria solo pueden ser investigados y sancionados por comportamientos descritos como falta en la ley vigente; 2) la antijuridicidad o ilicitud sustancial, es concebida como la afectación objetiva a los deberes funcionales, esto es sin que sea necesario un daño material de esta manera basta la sola infracción de Art 6 de la Carta Política los deberes contentivos en la carta política, las leyes los reglamentos, los contratos de trabajo, los manuales de funciones para que se configure el injusto disciplinario⁵ por lo cual la conducta para que sea considerada sustancialmente ilícita debe atentar contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines⁶, y 3) la culpabilidad, concebida la posibilidad de exigir otro comportamiento al sujeto disciplinado⁷, la cual solo puede darse por las modalidades de culpa o dolo⁸. (Subraya el Despacho).

Ahora bien, los disciplinados no sólo no tenían el deber funcional de consultar el listado de precios de referencia de a DIAN al momento de las inspecciones aduaneras, sino que los

POR EL CUAL SE RESUELVE EN SEGUNDA INSTANCIA EL RECURSO DE APELACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE 1704-01-2015-194

mismos, como ya se estableció en líneas anteriores, deben ser tomados con "carácter indicativo para el control del valor declarado", no rechazan automáticamente el "valor de Transacción declarado", deben "tomarse como una medida de control", sirven para sustentar "las dudas del valor declarado", pueden ser utilizados junto con las "fuentes citadas en el artículo 237" del Decreto 2685 de 1999, son "un parámetro de comparación y su aplicación no es obligatoria". Adicionalmente no se han "emitido lineamientos o directrices indicando la obligatoriedad" de su consulta.

Y por último, tal como lo declaró la Doctora INIRIDA PAREDES, debe tenerse en cuenta que el valor en aduana de las mercancías importadas se verifica en el control posterior y no en el control previo, y que en materia de valoración aduanera es "obligatorio partir del precio realmente pagado o por pagar contenido generalmente en la factura comercial.

Por todos los anteriores motivos, este Despacho acoge el primero de los argumentos de apelación presentados por la defensa, relacionados con la no obligatoriedad de consultar los listados de precios de referencia de la DIAN, el cual, si bien fue formulado en favor de la señora XXXXX XXXXX, será acogido para ambos sujetos procesales en razón a que el director del proceso no distinguió el actuar de aquella respecto del actuar del señor XXXXX XXXXX, cuando éstos fueron diferentes, pues mientras ella otorgó levante a la declaración de importación No. 032012000774248-1 (autoadhesivo 07237271367894) de 8/06/2012 y a la declaración de corrección No. 032012000774325-9 (autoadhesivo 23231026995741) de 16/06/2012, él otorgó levante a las declaraciones de legalización No. 0500700527416-1 (autoadhesivo 07839270066146) y No. 0500700527418-6 (autoadhesivo 07839270066153) de 11/12/2012, último que, como bien lo anotó la defensa, habían sido autorizados porque el usuario pagó "EL 75% POR CONCEPTO DE RESCATE", como da cuenta el folio 654 del expediente.

En resumen, por las razones expuestas no se confirmará el fallo impugnado y en su lugar se absolverá a los procesados XXXXX XXXXX y XXXXX XXXXX de la conducta imputada en el auto de pliego de cargos de fecha 14 de julio de 2016, referente a la falta disciplinaria gravísima prevista en el artículo 48 numeral 50 de la Ley 734 de 2002, en el entendido que aquellos no incumplieron el deber funcional que les asistía al momento de realizar la inspección aduanera a las declaraciones de importación ampliamente mencionadas, lo cual, dicho sea de paso, releva al Despacho de pronunciarse sobre los otros argumentos de apelación presentados por la defensa.

En tal virtud, la Directora General (E) de la UAE Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC, en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

PRIMERO. REVOCAR totalmente la Resolución No. 17317-00036 de fecha 23 de diciembre de 2016, por medio de la cual la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC, profirió fallo sancionatorio de primera instancia y sancionó con DESTITUCIÓN e INHABILIDAD GENERAL POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS, a los servidores públicos XXXXX XXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXX y XXXXX XXXXX, identificada con cédula de ciudadanía No. XXXXX, de conformidad con las razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, **ABSOLVER** a los servidores públicos XXXXX XXXXX y XXXXX XXXXX, de la falta disciplinaria establecida en el artículo 48, numeral 50 de la Ley 734 de 2002.

TERCERO. NOTIFICAR el contenido de esta decisión a los sujetos procesales, de conformidad con las previsiones legales, contenidas en los artículos 101 y 107 de la Ley 734 de 2002.

POR EL CUAL SE RESUELVE EN SEGUNDA INSTANCIA EL RECURSO DE APELACIÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE 1704-01-2015-194

CUARTO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

QUINTO. La presente decisión queda en firme el día de su suscripción, pero sus efectos jurídicos se surten a partir de la notificación, tal como lo dispone el inciso segundo del artículo 119 de la Ley 734 de 2002.

SEXTO. Una vez surtida la notificación del presente fallo, **REGISTRAR** la decisión ante la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, conforme lo ordena el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, en armonía con el artículo 48 numeral 57 ibídem.

Igualmente, **REMITIR**, copia de la presente decisión al Director General de la DIAN para que proceda, en su calidad de nominador, a realizar los registros a que hubiere lugar.

SEPTIMO. Ejecutoriada materialmente esta decisión, libradas las comunicaciones de ley,

DEVUÉLVASE el expediente al Despacho de origen para to de su cargo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.



MARCELA MONCADA BARRERA
Directora General (E)